

1501029-43.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jose Luis Pereira Andrade

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 3ª Vara Cumulativa

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... o delegado ratificou o flagrante de tráfico de drogas. Eu já conhecia o HIGOR dos meios policiais pelo tráfico de entorpecentes. Havia duas pessoas. O HIGOR estava agachado. Quando ele viu a viatura, ele levantou e jogou algo. Nós vimos claramente isso e o outro indivíduo correu. [destaques meus]

PM LUIZ GUILHERME CANO: Na data dos fatos, a equipe de Força Tática ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

3ª Vara Cumulativa

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista-SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501029-43.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501029-43.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIGOR JOSE ANGELICO

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Jose Luis Pereira Andrade

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de HIGOR JOSÉ ANGÉLICO, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, ao argumento de que, em 15/09/2021, por volta das 23h30min, na Rua Aristides Moretti, na altura do nº 82, Ibaté, Lençóis Paulista, policiais militares teriam avistado o réu atirando um objeto no quintal de uma residência quando visualizou a viatura, sendo que, abordado e, com o auxílio da respectiva morada, os agentes teriam constatado que o objeto em questão continha seis porções de cocaína. Aduziu o Parquet que os militares foram até o local onde o réu estava agachado, onde teriam localizado outras 68 porções de cocaína, idênticas às que estavam com HIGOR, totalizando as 74 em 9,25 gramas, além de uma porção bruta de crack, de 7,47 gramas. Alegou que, com o réu, ainda foram encontrados R\$ 20,00, sendo, então, conduzido à delegacia de polícia, onde foi lavrada a prisão em flagrante. Requereu, assim, que o réu fosse incurso no tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com a respectiva condenação.

A denúncia, de fls. 86/88, está acompanhada do auto de prisão em flagrante de fls. 01/85, do qual consta que, no plantão judiciário, foi decretada a prisão preventiva do réu (fls. 62/65). Outrossim, no ato de oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu a realização de perícia no celular que foi apreendido com o réu

(fl. 89).

Notificado, o réu, mediante advogado nomeado, apresentou defesa preliminar às fls. 107/120, instruída com os documentos de fls. 121/123, arguindo preliminar de ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, porquanto, quando dos fatos, havia um outro indivíduo consigo e que conseguiu fugir, não tendo sido a droga encontrada em sua posse (do réu), sendo que parte da droga encontrada estaria em um cano de escoamento fluvial. No mérito, aduziu ser o caso de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/2006, por não haver evidências da traficância, e que a droga que estava efetivamente consigo – seis porções – seria compatível com o uso. Relatou ter ocupação lícita, tendo condições de adquirir o entorpecente para consumo. Ainda, requereu a revogação da prisão preventiva.

Em decisão de fls. 128/129, a denúncia foi recebida, sendo indeferido o pedido de concessão da liberdade provisória.

Às fls. 133/134, foi designada audiência virtual de instrução (em decorrência da pandemia de Covid-19) para o dia 16/12/2021.

Os laudos periciais do telefone e dos entorpecentes foram juntados às fls. 158/166 e 167/171, respectivamente.

Na audiência, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela Acusação e duas pela Defesa e o interrogatório do réu. Após, foi decretado o encerramento da instrução, oportunizando-se às partes a apresentação de alegações finais escritas (fls. 190/192).

O Ministério Público ofereceu seus memoriais às fls. 195/202, ratificando os termos da denúncia, pugnando pela decretação de pena privativa de liberdade, com exasperação na primeira fase da dosimetria em razão da quantidade de droga e por ser de mais de uma espécie e na segunda, pela reincidência específica, no regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais às fls. 212/224, aduzindo inexistirem provas que incriminem o réu, não tendo qualquer pessoa visto atividades de mercancia por ele praticada, considerando-se que o local inclusive é ponto de venda de drogas, podendo os entorpecentes pertencer a qualquer outra pessoa. Aduziu que o período era noturno, de pouca visibilidade, não se podendo atribuir sem sombra de dúvidas a propriedade da droga com o réu. Sustentou a imprestabilidade da perícia realizada no telefone do réu, já que nada de relevante teria sido encontrado, de modo que existiriam dúvidas que devem ser interpretadas a seu favor, requerendo, assim, a sua absolvição. Eventualmente, requereu a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/2006 ou, ao menos, que a pena fosse aplicada no mínimo legal.

Após, os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistindo preliminares ou nulidades a serem sanadas, passo diretamente ao julgamento.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente, sendo o caso de desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal.

Isso porque, embora a materialidade dos fatos esteja estampada no boletim de ocorrência (fls. 07/09), no auto de exibição/apreensão (fls. 10/11), no laudo pericial da droga (fls. 167/171) e na prova oral colhida tanto na fase policial como em contraditório, a traficância não restou demonstrada de forma cabal.

Ouvidas em juízo, as testemunhas policiais afirmaram aproximadamente o seguinte, conforme anotações deste magistrado:

PM ALISON ALVES: No dia dos fatos, nós estávamos em patrulhamento pela Força Tática no Bairro Ibaté. Essa rua já é de conhecimento que ocorre tráfico de entorpecentes. De imediato, nós avistamos dois indivíduos: um sentado próximo ao cano de água na calçada e o outro em pé, que, ao perceber a viatura, se evadiu. O indivíduo que estava sentado levantou, jogou algo em uma casa e saiu correndo, mas nós conseguimos abordá-lo. Na revista pessoal, ele falou que tinha R\$ 5,00 com ele, mas foram achados R\$ 20,00. De imediato, a gente foi à casa em que ele tinha jogado algo, a moradora franqueou a entrada e deixou a gente revistar o quintal dela. Eu achei um saco jogado com seis eppendorfs. Voltamos próximo ao local onde o

indivíduo estava sentado, e, no cano de água, foi achada mais uma sacola com 68 eppendorfs de cocaína e uma porção bruta de pedra de crack. O HIGOR foi questionado a respeito, e negou que o entorpecente era dele. A equipe o presenciou jogando o objeto na casa. A proprietária também relatou para a gente que não aguentava mais essa situação de venda de entorpecentes em frente à residência dela. Diante dos fatos, nós pegamos os entorpecentes e o HIGOR e fizemos a apresentação no CPJ de Bauru, e o delegado ratificou o flagrante de tráfico de drogas. Eu já conhecia o HIGOR dos meios policiais pelo tráfico de entorpecentes. Havia duas pessoas. O HIGOR estava agachado. Quando ele viu a viatura, ele levantou e jogou algo. Nós vimos claramente isso e o outro indivíduo correu. [destaques meus]

PM LUIZ GUILHERME CANO: Na data dos fatos, a equipe de Força Tática realizava patrulhamento pelo Jardim Ibaté, que já é conhecido pelo tráfico de drogas. Nós avistamos dois indivíduos que já eram conhecidos do meio policial. Eles estavam agachados na via próximo a calçada. No instante em que nós nos aproximamos deles, eu visualizei o HIGOR arremessando algo sobre um muro, sendo que o outro indivíduo que estava junto com o HIGOR empreendeu fuga do local. Em busca pessoal no HIGOR, ele informou que não teria nada ilícito e que teria apenas R\$ 5,00. No entanto, em revista, a gente acabou encontrando R\$ 20,00 com ele. Indagado a respeito sobre o que ele teria lançado sobre o muro, ele negou. Porém, eu claramente o vi fazendo o lançamento de um objeto sob o muro. Findada a busca ao HIGOR, eu realizei contato com a moradora da residência onde o objeto havia sido lançado, e ela fraqueou a nossa entrada, nos acompanhou e ressaltou que ela já estava cansada da mercancia de drogas em frente à residência dela: tanto de pessoal realizando venda, quanto de usuários de drogas. No entanto, ela temia pela sua integridade física caso ela tomasse alguma medida acabar com isso. No quintal da residência dessa senhora, foi encontrada uma espécie de um pacote com seis eppendorfs de cocaína. Retornamos à rua no local onde os indivíduos estavam agachados e nós encontramos dentro da tubulação de água mais uma sacola com 68 eppendorfs, os quais estavam embalados com a finalidade de venda. Nessa sacola, também havia uma porção bruta de crack, porque eles cortam e vendem a droga esfarelada para pessoas na rua. Em contato com o HIGOR, ele confessou que estava realizando o tráfico. Eram duas pessoas que estavam agachadas, mas eu não me recordo o nome dessa outra pessoa. O dia em que a força tática está na rua, porque nós trabalhamos um dia sim e outro não, eles não ficam na rua. Quando a gente sai de folga, não ficam outros policiais de Força Tática. As equipes ficam no atendimento de ocorrências, e a equipe de Força Tática não atende ocorrência. Damos ênfases para roubo, furto, ocorrências envolvendo a vida e o tráfico de drogas. [destaques meus]

Em seguida, colheram-se os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela Defesa:

ADRIANA REGINA ZANELATO: Eu não sou parente nem amiga íntima do HIGOR. Eu não presenciei nada em relação aos fatos. O que eu sei do HIGOR é que ele é usuário de maconha. Eu sei disso porque o HIGOR é meu vizinho e eu já vi a mãe dele brigar muito com ele por causa disso. Eu nunca presenciei nenhuma atividade ilícita praticada pelo HIGOR. Também nunca vi nenhuma atividade ilícita praticada por amigos do HIGOR. O HIGOR trabalhava com o pai dele. Ele era autônomo, sem registro. É comum a prática de entorpecentes nas imediações do bairro.

SANDRA VALGOLE: Eu não sou parente nem amiga íntima do HIGOR, eu trabalhei com ele. Eu não presenciei os fatos. Eu era gerente no local onde o HIGOR trabalhou comigo durante seis meses. A gente trabalhava juntos em uma lanchonete, e eu nunca presenciei nada de errado nele. Ele nunca comentou nada sobre drogas. Na última vez em que eu conversei com o HIGOR, ele me disse que estava trabalhando com o pai dele autônomo. No ambiente de trabalho, o HIGOR era uma excelente pessoa, muito educado, atencioso e nunca desrespeitou ninguém. Eu nunca presenciei nenhuma atividade ilícita praticada por ele no ambiente de trabalho, em hipótese alguma.

Finalmente, o réu foi interrogado:

O que eu tenho a dizer é que no dia dos fatos eu estava em casa e fui convidado para ir para um churrasco próximo a essa rua. Eu tinha R\$ 60,00. Após passar nessa rua dos fatos, eu avistei um menino sentado na esquina e pedi para ele seis pinos

de cocaína para o meu uso. Eu subi a rua para ir ao churrasco e avistei a viatura. Fiquei com medo e dispensei os seis pinos de cocaína na casa da mulher em que foram achados. Após os policiais me enquadrarem, eles desceram e enquadraram mais dois meninos que estavam na esquina. Eu estava subindo a rua sozinho. Não havia ninguém perto de mim e em momento nenhum eu estava agachado. Eu falei que realmente não tinha jogado a droga porque eu estava com medo, mas, após eles entrarem na casa da mulher e acharem a droga, eles voltaram até mim, começaram a me bater, me algemaram e me colocaram na viatura. Eles me levaram até a minha casa e perguntaram se iriam achar algum tipo de entorpecente, e eu falei que não iam achar, que eu só tinha comprado seis pinos para o meu uso e que eu não era traficante. Me levaram à delegacia de Bauru, e foi lá que eu fui ter conhecimento do restante dessas drogas. Eu falei para os policiais que a droga não era minha. Eu falei que a droga que era minha eram só os seis pinos.

A dinâmica das provas colacionadas aos autos não indica de forma indene de dúvidas a traficância.

A prova oral torna incontroverso que o réu efetivamente estava na companhia de um terceiro não identificado, quando, então, ao virem a viatura policial se aproximando, um deles, o réu, atirou uma sacola dentro do quintal de uma casa nos arredores, ao passo que o outro fugiu. Ainda, os policiais abordaram o réu, foram até a casa onde ele dispensou a sacola e constataram lá que nela havia seis porções de cocaína, as quais o réu reconhece como suas, por ter comprado junto ao terceiro. Em seguida, os militares saíram e, próximo ao local onde o réu estava com o terceiro, em um cano de escoamento fluvial, encontraram uma sacola, com mais 68 eppendorfs de cocaína, idênticos aos seis que estavam na sacola, além de uma porção bruta de crack. Na revista pessoal, foram encontrados com o réu R\$ 20,00. Esses são os fatos.

Pois bem.

Em que pesem as alegações acusatórias, não há elemento seguro que ligue o réu à propriedade das 68 porções de cocaína e da porção bruta de crack senão o fato de ele realmente estar portando (e depois se livrando) seis pinos de cocaína.

O réu sempre manteve sua versão de que não estava a traficar, assumindo apenas a propriedade das seis porções de cocaína por tê-las comprado do terceiro que empreendeu fuga. Outrossim, a baixa quantia R\$ 20,00 não faz presumir de modo algum que ele havia vendido drogas até então, ressaltando-se que ninguém de fato viu ato de mercancia praticado pelo réu, como se percebe dos depoimentos policiais.

Aliás, conquanto os militares tenham demonstrado firmeza nos seus depoimentos, eles são contraditórios entre si em um ponto, eis que um deles afirma que o réu não confessou informalmente a propriedade da droga, ao passo que o outro o afirma, tornando duvidosa tal circunstância.

Acrescente-se que ninguém viu o réu portando ou na posse das drogas encontradas no cano fluvial, sendo perfeitamente possível e plausível que o terceiro que fugiu fosse o dono original de toda a droga e que, inclusive, estivesse vendendo as seis porções ao réu.

As testemunhas defensivas afirmaram que o réu tinha ocupação lícita, de modo que, ao menos em tese, teria condições de adquirir droga para seu consumo.

Foi também periciado o telefone encontrado com o réu, não tendo sido encontrado qualquer elemento relevante que indicasse a traficância praticada por HIGOR.

Não houve qualquer denúncia anônima nem foi montada campana, tendo os policiais visualizado apenas o réu e o terceiro, podendo este ser o vendedor e aquele o comprador de seis porções, factíveis no que toca ao consumo próprio.

Logo, não tendo sido testemunhado qualquer ato de compra e venda de drogas nem que o réu estivesse na posse dos demais entorpecentes encontrados, sendo crível que a droga fosse de outra pessoa que estava efetivamente no local, impossível um decreto condenatório por tráfico. A propósito, em caso apreciado nesta Comarca, o E. TJSP decidiu o seguinte:

Tráfico de drogas. Absolvição decretada em 1ª instância. Apelo ministerial pretendendo a condenação. Inadmissibilidade. Negativa do acusado. Alegação de que estava no local com seu primo. Dúvida quanto à propriedade do entorpecente localizado em terreno baldio. Ausência de elementos concretos do intuito mercantil.

Compatibilidade entre as versões do réu e a dos policiais que efetuaram a condução do réu ao distrito policial. Possibilidade de uma e outra serem verdadeiras. Consagração do in dubio pro reo. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0012769-49.2014.8.26.0196; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/07/2017; Data de Registro: 12/07/2017)

Outrossim, analisando-se detidamente as alegações finais acusatórias, data venia, o Parquet está a presumir a traficância basicamente em razão dos antecedentes do réu. Em suma, não se exclui a possibilidade de ter havido o tráfico praticado pelo réu. Entretanto, o Ministério Público não produziu qualquer prova de que a droga encontrada nas proximidades do réu fosse sua, encontrando-se com ele apenas as seis porções de cocaína, compatíveis com o uso e em relação às quais tampouco se verificou ato de comercialização.

Passagens anteriores ou mesmo a prisão posterior do réu em outro contexto servem como eventuais elementos para aumento de pena, mas não como prova do delito em si. Assim, na ausência da necessária certeza quanto ao tráfico, impõe-se a desclassificação para o delito de posse para uso.

PASSA-SE, ASSIM, À DOSIMETRIA.

Embora se trate de réu reincidente, a diminuta quantidade da droga e o fato de o réu já estar preso há mais de quatro meses enseja a aplicação apenas da medida de advertência.

No entanto, não é o caso nem mesmo de aplicação da medida em questão, operando-se a detração imprópria, eis que o réu se encontra preso desde 15/09/2021, sendo o caso de extinção da punibilidade pelo cumprimento de qualquer pena que lhe fosse aplicada, pois qualquer medida lá prevista é menos severa do que a prisão, teoria encampada pelo Desembargador Guilherme de Souza Nucci. A propósito:

Apelação. Tráfico de entorpecente. Policiais militares, em patrulha ostensiva, avistaram o réu na condução de veículo, sendo abordado. Em revista veicular nada de ilícito foi encontrado, mas, em busca pessoal, o réu possuía uma porção de cocaína, envolta em invólucro plástico, com peso bruto de 65,57 gramas. Materialidade comprovada. A autoria, contudo, não restou sobejamente delineada nos exatos termos propostos pela exordial acusatória, remanescendo dúvidas acerca da posse de um montante de cocaína, com peso bruto de 65,57 gramas (fotografia fl. 31), sem ter sido aferida a massa líquida, para fins de fornecimento, ainda que gratuito, a terceiros. Reduzido volume de droga e ausência de outros elementos contundentes que efetivamente demonstrem a posse para fins mercantis impossibilitam a condenação do réu nos termos da denúncia. O Estado precisa efetivamente investigar os fatos, não cabendo ao Poder Judiciário extrair de uma apreensão a existência presunçosa de posse para fins mercantis. De rigor, a desclassificação para o delito constante do artigo 28, da Lei de Drogas. Ilógica aplicação de qualquer pena. Réu preso durante toda a instrução. Detração imprópria. Extinção da punibilidade. Restituição dos bens apreendidos. Recurso defensivo parcialmente provido. Expedição de alvará de soltura clausulado. (TJSP; Apelação Criminal 1500209-85.2021.8.26.0024; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Andradina - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/12/2021; Data de Registro: 11/12/2021)

Colhe-se do julgado:

[...] Dessa forma, em prol do postulado do in dubio pro reo, deve-se afastar a tipificação quanto ao tráfico ilícito de drogas, desclassificando a conduta do recorrente para o delito constante do artigo 28, da Lei 11.343/06, cuja autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas.

Ilógica é a imposição de qualquer espécie de pena, nesse momento, porquanto o apelante permaneceu encarcerado indevidamente durante toda a instrução processual, sendo, inclusive, impossibilitado de recorrer em liberdade.

A partir do momento em que a instrução criminal aponta por delito diverso daquele ensejador da prisão em flagrante, sobretudo tratando-se de delito não punido com pena privativa de liberdade, incoerente se torna a imposição de qualquer outra pena.

Solução, nesses casos, é a aplicação do mesmo entendimento da detração na pena de

multa.

[...]

Destarte, em consonância com a coerência do sistema, justo se faz o reconhecimento da extinção da punibilidade, em favor do réu, o qual já cumpriu pena mais severa daquela prevista no preceito secundário da norma transgressora. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória entabulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para declarar HIGOR JOSÉ ANGÉLICO incurso no tipo previsto art. 28 da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a medida de advertência, declarando, por outro lado, a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO RÉU, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo do réu nomeado pelo Convênio DPE/OAB.

Com fundamento na Lei 11.343/06, art. 50-A e nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, Tomo I, Capítulo V, Seção V, item 107, determino a incineração da substância entorpecente apreendida nos autos e, por ocasião da incineração, deverá ser lavrado o respectivo auto, encaminhando-se cópia para este Juízo.

Determino, ainda, a devolução do dinheiro apreendido ao réu (R\$ 20,00) e do telefone celular, já que não comprovada a sua origem ilícita.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Lencois Paulista, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA